

第36問

甲は、球場でプロ野球観戦に興じていたところ、いつの間にか、自己の財布がなくなっていることに気が付いた。甲がどこかに財布が落ちていないかと周辺を探したところ、すぐ近くに座っているAが甲の財布を盗み、ひじ掛けの所に、A自身の財布と一緒に置いているのを見つけた。甲は、返してもらおうと思ったが、Aの風貌が強面であったため、言い出せず、どうしたものかと悩んでいた。

すると、Aは、試合が終わったため、席を立ったが、甲及びAの財布を持ち出すのを失念し、そのまま放置した。甲は、これを見て、すぐにでも財布を取り戻そう、腹いせにAの財布も持ち去ってやろうと思ったが、急に動くと思われたい、Aが立ち去ってから2分後であり、席から直線距離にして30メートル離れた球場の入場ゲート付近を歩いている時に、甲及びAの財布をつかみ、自己の懐に入れた。

その後、Aは、席を立ってから約10分後、球場の外に出てから、さらに約500メートル歩いたところで、財布がないことに気が付き、慌てて席へ戻ったが、既に甲に持ち出され、甲もその場にいなかった。

甲の罪責について、論じなさい。

第1 Aの財布について

窃盗罪（235）の成否を検討すべきであるが、占有の有無によっては占有離脱物横領罪（254）を検討することになる（**論点** 占有の有無の判断方法 **論** 司H27）。

判例（最判昭32.11.8）は、「刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であって、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によって一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りると解すべきである。しかして、その物がなお占有者の支配内にあるというを得るか否かは通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によって決するの外はない。」とする。

本問では、以下のような事情を考慮することになるだろう。

- ・甲は、Aが立ち去ってから2分後、席から直線距離にして30メートル離れた球場の入場ゲート付近を歩いている時に、甲及びAの財布を領得しているから、場所的・時間的離隔が小さいこと
- ・問題となっている場所は、プロ野球の球場であり、公園などと比べ、場所の開放性が弱いこと
- ・Aは、席を立てってから約10分後、球場の外に出てから、さらに約500メートル歩いたところで、財布がないことに気が付いており、財物の所在を明確に認識していること

総合 195 頁 論証 82 頁

第2 甲の財布について

甲の財布にAの占有が及ぶか否かという点については、上記のとおりである。

もっとも、甲の財布については、Aの占有下にある「自己の財物」であるから、242条の適用が別途問題となる（**論点** 財産犯の保護法益論 **論** 司H27,予R3）。

この点について、判例（最決平元.7.7【百選Ⅱ26】）は、「被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は借主の事実上の支配内にあったことが明らかであるから、かりに被告人にその所有権があったとしても、被告人の引揚げ行為は、刑法242条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない」として、占有説に立ちながら、違法性阻却の可能性を認めている。この違法性阻却については一般に自救行為であると解されている（**論点** 自救行為 **論** 司H27）。

総合 193 頁 論証 81 頁

同決定の調査官解説によれば、違法性阻却の肯否を判断するに当たっては、占有の内容、占有を回復する者の権利利益の内容、占有回復の手段等が考慮される。

本問では、以下のような事情を考慮すべきだろう。

- ・Aの甲の財布に対する占有は違法であること
- ・Aの風貌が強面であったため、甲が財布を返してほしいと言い出せなかったこと
- ・甲はAに対して有形力を行使しているわけではないこと
- ・甲の財布の取戻しについてみれば、違法な目的はないこと

総合 80 頁 論証 27 頁

第1 Aの財布について

1 甲がAの財布をつかみ、自己の懐に入れた行為について、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗罪（235条）が成立しないか。

Aの財布はAの所有にかかるから「他人の財物」に当たることは明らかである。

2(1) 一方、窃盗罪の実行行為は「窃取」、すなわち占有者の意思に反した占有侵奪であり、被害者に占有が認められない場合には同罪は成立せず、占有離脱物横領罪（254条）が成立するにとどまる。

(2) そこで、占有の有無の判断方法をいかに解すべきか。

刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であって、占有の事実と占有の意思から構成される。しかし、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によって一様ではないため、社会通念によって決するほかはない。

(3) 本件では、甲は、Aが立ち去ってから2分後、席から直線距離にして30メートル離れた球場の入場ゲート付近を歩いている時に、Aの財布を領得しているから、場所的・時間的離隔が小さい。

また、Aは席を立てってから10分後、500メートルほど離れた時点で忘れ物に気付いて慌てて戻っている。このことから、Aはいまだ財布を忘れた場所を明確に記憶し、かつすぐに取りに戻っているものといえ、Aの占有の意思が比較的強く認められる。

さらに、一般にプロ野球の球場は、チケットを所持する者しか入場ができないから、公園など公衆が自由に出入りできる場所と比べ

1

ば、場所の開放性が弱い。

以上のような事情を総合的に考慮すると、本件ではAにAの財布の占有が認められる。

したがって、「窃取」の要件も満たす。

3 甲には故意（38条1項）及び不法領得の意思に欠けるところもないから、上記行為に窃盗罪が成立する。

第2 甲の財布について

1 甲の財布をつかみ、懐に入れた行為について、Aの意思に反した占有侵奪であるとして、同じく窃盗罪の成否が問題となる。

2(1) もっとも、甲の財布は甲の所有物であるから、「他人が占有」する財物でなければならない（242条）。Aの財布と同様、甲の財布についてもAの占有が及んでいると解されるが、Aは甲の財布を盗んだものであって、それについては適法な占有権原を有しない。

では、そのような占有であっても、同条にいう「占有」に当たるか。

(2) 奪取罪の保護法益が究極的には本権であることは否定できないが、自力救済が禁止されている中では、社会の平穏や秩序を保護すべきである。

したがって、奪取罪の保護法益は、占有も含むと考える。

よって、「占有」には、本件に基づく占有だけでなく、およそいかなる占有も含まれると解する。

(3) Aの甲の財布に対する占有は違法であるが、242条にいう「占

2

有」に当たる。

したがって、甲の財布は、「他人が占有」する「自己の財物」に当たり、甲の上記行為は、第1と同様、窃盗罪の構成要件に該当する。

3(1) もっとも、甲は球場内でAに奪われた財布を取り返すべく上記行為に及んでいる。そこで、自救行為として違法性が阻却されないか。

(2) 自救行為とは、正当防衛(36条1項)を認めるだけの侵害の急迫性・現在性は存在しないが、国家機関の救済を待っているのは権利の回復が困難になる場合、侵害者に対し自ら実力により救済を図る行為をいう。

そのような概念が認められるか、明文なく問題となる。

この点について、国家機関が法秩序の回復をするいとまがなく、権利保護の緊急性・必要性が高度に認められる場合がある。このような場合に、そのまま放置すれば法が不法を擁護する結果となりかねない。

したがって、これを許容する余地はあるというべきである。

ただし、自力救済の禁止の趣旨を没却するおそれがあるから、これを広く認めることはできない。すなわち、次のような厳格な基準の下で認められるというべきである。

まず、①法益に対する違法な侵害がなされたこと、及び②侵害された法益の回復を国家の救済機関の手に委ねるときは、回復が事実上不可能になるか、又は著しく困難になる明白な事態にあることが必要である。また、③自救のためになされた行為が、その事態における直接

3

的な侵害回復行為として、社会観念上、相当なものであることも必要である。さらに、主観的正当化要素として、④自救の意思も要求すべきである。

(3) まず、上記のように、Aの甲の財布に対する占有は違法である(①充足)。

そして、甲はAに球場内において自己の財布を盗まれたのであって、Aの風貌が強面であったため、甲が財布を返してほしいと言い出せなかったことも考えると、甲がAに直接返還を要求することは難しく、Aが財布を置き忘れた隙に取り返さなければ、取り返す機会を失うおそれがある。そうだとすれば、侵害された法益の回復を国家の救済機関の手に委ねるときは、回復が事実上不可能になるか、又は著しく困難になる明白な事態にあるといえる(②充足)。

また、甲はAに対して有形力を行使しているわけではなく、Aが置き忘れた甲の財布を持ち去っているにすぎない。したがって、回復手段としても相当である(③充足)。

さらに、甲は、甲の財布についてみれば、Aに盗まれた自己の財布を取り返すことだけを目的として上記行為に及んでいると考えられるから、自救の意思も肯定できる(④充足)。

したがって、自救行為として違法性が阻却される。

4 以上より、甲の財布について窃盗罪は成立しない。

以上

4